

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
14254/2555

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์  
นายคาน เสน่หา

โจทก์  
จำเลย

ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง

พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.อ. (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 มาตรา 3

ตาม ป.อ. มาตรา 277 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่โดย พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม  
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2550 มิได้บัญญัติวางหลักในเรื่องความผิด  
สำเร็จของการกระทำชำเราแต่อย่างใด แต่เป็นการให้ความหมายของการกระทำ  
ชำเรา จากเดิมที่จำกัดเฉพาะการใช้วัยวะเพศต่ออวัยวะเพศเท่านั้น ให้ขยายกว้าง  
ออกไปโดยให้รวมถึงการใช้วัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับทวารหนักหรือช่องปาก  
ของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นด้วย ที่  
โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยว่า จำเลยพยายามกระทำ  
ชำเราผู้เสียหายที่ 1 เนื่องจากจำเลยไม่อาจสอดใส่อวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปใน  
อวัยวะเพศของผู้เสียหายจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 91,  
277, 279, 284, 317 และริบมีดใต้แบบตะขอของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง คืบมิดโต้แบบตะขอของกลางแก่เจ้าของ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80, 277 วรรคสาม, 279 วรรคแรก, 283 ทวิ วรรคสอง, 317 วรรคสาม การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานพยายามกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจารเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานพยายามกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 6 ปี ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่ออนาจาร เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 9 ปี ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจาร จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 2 กระทง จำคุก 10 ปี รวมจำคุก 25 ปี คำขอให้ริบมิดของกลางให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังว่า ขณะเกิดเหตุเด็กหญิงวารุณี ผู้เสียหายที่ 1 พักอาศัยอยู่กับนายแก้ว ผู้เสียหายที่ 2 ซึ่งเป็นปู่และเป็นผู้ปกครองดูแล จำเลยเป็นน้องนางทิพย์ มีอาณาเขตบ้านติดต่อกัน และสามารถเดินผ่านบ้านนางทิพย์ไปยังบ้านจำเลยได้

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 หรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า ในความผิดที่โจทก์ฟ้อง จำเลยฐานพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 นั้น แม้จำเลยไม่อาจสอดใส่อวัยวะเพศเข้าไปได้ก็ตาม ก็เป็นการใช้อวัยวะเพศของจำเลยกระทำกับอวัยวะเพศของผู้เสียหายที่ 1 ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ ถือว่าเป็นการกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 แล้ว หาใช่เพียงแต่พยายามกระทำชำเราไม่ แต่เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษฐานพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ศาลก็ไม่อาจลงโทษฐานกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 ได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอของโจทก์ คงลงโทษพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 เท่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคหนึ่ง เห็นว่า ตามมาตรา 277 วรรคสอง ที่แก้ไขใหม่ มิได้บัญญัติวางหลักในเรื่องความผิดสำเร็จของการกระทำชำเราแต่อย่างใด แต่เป็นการให้ความหมายของการกระทำชำเรา จากเดิมที่จำกัดเฉพาะการใช้อวัยวะเพศต่ออวัยวะเพศเท่านั้น ให้ขยายกว้างออกไปโดยให้รวมถึงการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับทวารหนักหรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่นด้วย ดังนี้ ที่โจทก์บรรยายฟ้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดของจำเลยว่า จำเลยพยายามกระทำชำเราผู้เสียหายที่ 1 จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยมาจึงไม่ถูกต้อง แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในส่วนนี้เพราะได้พิพากษาลงโทษจำเลยตามฐานความผิดที่รับฟังได้ตามโจทก์ฟ้องแล้ว

อนึ่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาให้ยกคำขอริบมีดของกลาง แต่ไม่ได้สั่งคืน  
ของกลางดังกล่าวแก่เจ้าของ ศาลฎีกามีอำนาจสั่งคืนแก่เจ้าของได้ตามประมวล  
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 49 และมาตรา 186 (9)

พิพากษายืน แต่ให้คืนมีดของกลางตามฟ้องแก่เจ้าของ

(อิสสระ นิมละมัย-ศรีอัมพร ศาลิคุปต์-กฤษฎีจิรัฐ คุณาจิรภรณ์)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นายวิเชียร พัฒนาไพศาล

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายอนันต์ ยมจินดา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ909/2552

ต้น

หมายเหตุ